

1500525-05.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... (o denunciado) estava praticando o tráfico de drogas no cruzamento das vias supramencionadas, local este já conhecido nos meios policiais como "ponto" de tráfico de drogas. Com base nas características das vestimentas informadas, os policiais se deslocaram até o local indicado e o investigado foi abordado. Em revista pessoal no denunciado, os policiais encontraram no bolso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500525-05.2021.8.26.0637 - Controle 2021/000529

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA

Aos 20 de outubro de 2022, às 15:30h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça MARCELO BRANDÃO FONTANA, do(a) Dr(a). Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas as testemunhas do rol acusatório, as arroladas pela Defesa e, ao final, o réu foi interrogado sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Pela Defesa foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Sidnei e Deisele, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra às partes, que se manifestaram mediante sistema de gravação. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA, por afronta ao disposto no art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006. Segundo consta na denúncia de fls. 84/89, *ipsis litteris*:

Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 25 de abril de 2021, por volta das

20h30min, na Rua Vista Alegre com a Rua Faustino Danelutti, Parque São Pedro, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA, qualificado às fls. 4 e 17/21, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) eppendorff's de Cocaína ("crack"), com peso líquido de 0,76 gramas (peso bruto 8,67g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 09 e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 13/14 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. O acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em seu poder e, após, comercializadas ao consumo de terceiros. Consta dos autos que, por ocasião dos fatos, policiais militares receberam informações anônimas de que um indivíduo (o denunciado) estava praticando o tráfico de drogas no cruzamento das vias supramencionadas, local este já conhecido nos meios policiais como "ponto" de tráfico de drogas. Com base nas características das vestimentas informadas, os policiais se deslocaram até o local indicado e o investigado foi abordado. Em revista pessoal no denunciado, os policiais encontraram no bolso esquerdo da bermuda um recipiente plástico contendo 08 eppendorff's de cocaína, bem como no bolso direito da vestimenta foi localizada a quantia de R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Ao ser questionado, o denunciado afirmou que não havia drogas em sua residência, contudo, disse que havia mais dinheiro, produto da comercialização dos entorpecentes. Na sequência, todos foram até a casa do acusado e no quarto dele os policiais encontraram a quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais). O denunciado confessou a prática do delito (fls. 04). As drogas e a quantidade em dinheiro foram apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 09). As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de COCAÍNA (fls. 13/14). O laudo definitivo será apresentado posteriormente. Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ("crack"), as informações prévias obtidas pelos policiais militares em relação ao comércio de entorpecentes praticado pelo denunciado, a quantidade de dinheiro apreendida, a confissão do denunciado acerca da traficância, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros.

Inquérito policial às fls. 01/78. Defesa prévia e documentos às fls. 110/117. Recebimento da denúncia às fls. 129/132. Realizada audiência nesta data; O Ministério Público reiterou o pleito condenatório em memoriais. A defesa, por seu turno, pugnou em caso de condenação por tráfico, manifestou por penas mínimas, aplicação da minorante especial, regime inicial menos gravoso e substituição por restritivas de direitos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

- No tocante à alegação de nulidade das provas colhidas, cumpre destacar que a Suprema Corte solveu, em sede de repercussão geral, a realização de busca e apreensão em crimes permanentes, dispensando-se o mandado judicial. A respeito, vide o excerto da ementa do RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado pelo Pleno em 05/11/2015:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. (...) A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Fixada a interpretação de

que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

Na situação em análise, observa-se que se trata de crime permanente, porquanto o réu trazia consigo as porções de drogas destinadas ao comércio espúrio. Desta forma, indiscutível que o estado flagrancial se prolonga no tempo, o que permite a revisa em prisão e flagrante.

Apesar da argumentação esposada pela defesa nos memoriais finais, incogitável que a Polícia Militar trabalhasse de acordo com tal raciocínio. Não era crível ou exigível que os militares realizassem investigação prévia ou campana. Ademais, os estupefacientes foram apreendidos em poder do réu, que praticava o crime na via pública.

Da mesma forma, inadmissível que os policiais resolvessem suspender a operação e fossem até a Delegacia de Polícia na manhã seguinte, formalizar uma representação para que a Autoridade Policial solicitasse uma ordem judicial para a busca. É mais do que óbvio que, se assim fosse, o acusado fugiria com as drogas.

Conforme já mencionado adrede, o Poder Constituinte Originário foi cauteloso ao estabelecer que “a casa é asilo inviolável”, permitindo o ingresso “em caso de flagrante delito”. E, no caso concreto que ora se escrutina em cognição exauriente, não se vislumbra nenhuma nulidade na conduta dos gendarmes, que dispunham de elementos concretos e seguros acerca da conduta criminoso. Não se pode ignorar que a Polícia Militar atua de forma preventiva e repressiva, mantendo contato direto com os fatos delituosos. Assim, seus atos devem ser interpretados de acordo com a situação concreta e sua candência, e não de forma confortável, indiferente e fria após o resultado. Além disso, o estado de flagrância do tráfico, na modalidade de “guardar” e “ter em depósito”, é permanente. Ora, havia um crime ocorrendo e os policiais militares estavam diante dos substratos suficientes para justificar a busca pessoal e na casa (que contou com a expressa concordância do increpado). Não há nada que inquie de nulidade as diligências levadas a efeito pelos policiais militares.

Compreender de forma diversa, como pretende a defesa, é desprezar o comando constitucional que permite a prisão em flagrante, mesmo dentro da casa, bem como premia o responsável pelo tráfico de drogas. Assim, não há que se falar em declaração de nulidade da busca e apreensão, tampouco dos atos derivados.

No mesmo sentir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA MEDIDA INVASIVA. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADA. ELEMENTOS FACTUAIS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R\$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes. 3. Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências. 4. A utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. 5. Neste caso, a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos foi empregada como circunstância negativa para exasperar

a pena-base. Já na terceira fase, foram indicados outros elementos, como a presença de caderno de anotações, balanças de precisão e elevada quantidade em dinheiro, de modo que não há que se falar em bis in idem, como bem destacado pelas instâncias antecedentes. 6. Diante da presença de circunstância judicial negativa, inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Além disso, a pena estabelecida em patamar superior a quatro anos de reclusão inviabiliza a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 729.576/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Em que pese a manifestação defensiva em memoriais finais, o edito condenatório em desfavor de VICTOR HUGO desvela-se insofismável, nos termos durante esposados. Destarte, encerrada a instrução probatória, cumpre destacar que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, de acordo com o auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), fotografias dos entorpecentes (fls. 10/11), laudos periciais (fls. 13/14), relatório final do Douto Delegado de Polícia (fls. 77/80), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:

A testemunha LUCIANO GRACIANO DA SILVA, policial militar, ouvido na fase inquisitiva às fls. 02, declarou *ipsis litteris* o seguinte: Informa que estavam em patrulhamento quando então receberam informações anônimas dando conta de que na esquina da Rua Faustino Danelute com Rua Vista Alegre, local já conhecido como sendo ponto de venda de drogas, haveria um indivíduo trajando camisa escura, boné vermelho e bermuda, promovendo o tráfico de drogas pelo local. Sendo assim, prontamente se deslocaram ao local dos fatos e, ao se aproximarem, com as luzes da viatura policial acesas, no intuito de ofuscar a visibilidade do referido indivíduo, conseguiram encontrá-lo, procedendo então à sua abordagem. Em busca pessoal, sendo o indiciado identificado como VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA, no bolso esquerdo de sua bermuda foi encontrado um recipiente plástico contendo em seu interior 8 (oito) "pinos" plásticos contendo substância petrificada aparentando ser "crack". No bolso direito do indiciado foi localizada a quantia de R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Indagado sobre a droga e sobre os valores, o indiciado espontaneamente afirmou ser de sua propriedade e que de fato estava comercializando o entorpecente. Indagado se haveria algo mais de ilícito em sua residência, prontamente o indiciado afirmou que apenas teria um pouco mais de dinheiro que também seria fruto de venda de drogas. Em diligência pela residência do indiciado, no quarto dele foi localizada ainda a quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais). Sendo assim, conduziram coercitivamente o autor a esta unidade policial. Em Juízo, LUCIANO disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento de polícia tática obtendo informações de inteligência de pessoa que estaria realizando a venda de entorpecentes, indicando as características do indivíduo. A equipe se dirigiu ao local encontrando o acusado, detentor das mesmas características apontadas. Informou que o acusado portava oito porções de crack, confessando a prática delitiva.

A testemunha CLEITON CESAR PACHECO, policial militar, ouvido na fase inquisitiva às fls. 3, declarou *ipsis litteris* o seguinte: Informa que estavam em patrulhamento quando então receberam informações anônimas dando conta de que na esquina da Rua Faustino Danelute com Rua Vista Alegre, local já conhecido como sendo ponto de venda de drogas, haveria um indivíduo trajando camisa escura, boné vermelho e bermuda, promovendo o tráfico de drogas pelo local. Sendo assim, prontamente se deslocaram ao local dos fatos e, ao se aproximarem, com as luzes da viatura policial acesas, no intuito de ofuscar a visibilidade do referido indivíduo, conseguiram encontrá-lo, procedendo então à sua abordagem. Em busca pessoal, sendo o indiciado identificado como VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA, no bolso esquerdo de sua bermuda foi encontrado um recipiente plástico contendo em seu interior 8 (oito) "pinos" plásticos contendo substância petrificada aparentando ser "crack". No bolso direito do indiciado foi localizada a quantia de R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Indagado sobre a droga e sobre os valores, o indiciado espontaneamente afirmou ser

de sua propriedade e que de fato estava comercializando o entorpecente. Indagado se haveria algo mais de ilícito em sua residência, prontamente o indiciado afirmou que apenas teria um pouco mais de dinheiro que também seria fruto de venda de drogas. Em diligência pela residência do indiciado, no quarto dele foi localizada ainda a quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais). Sendo assim, conduziram coercitivamente o autor a esta unidade policial. Em Juízo, CLEITON declarou que no dia dos fatos foi informado pela equipe de inteligência de que havia uma pessoa fazendo o tráfico de entorpecentes, indicando as vestes e características físicas do indivíduo. Deslocou-se ao local, encontrando acusado que trajava as vestes mencionadas. Durante busca pessoal, encontrara porções de entorpecentes, tendo o acusado confessado o delito.

A testemunha de defesa ANDRESA LIMA SILVA relatou em Juízo que seu sobrinho é ótima pessoa, trabalhadora e de boa índole. Relatou que seu sobrinho era usuário de maconha, mas trabalhava de forma

O acusado VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA em fase inquisitiva, fls. 04, declarou *ipsis litteris* o seguinte: Confessa que por estar desempregado e não conseguir trabalho algum, recentemente começou a pegar drogas por conta própria e comercializá-las. Confessa que estava traficando a droga apreendida em sua posse e que os valores encontrados em seu bolso e em sua residência são fruto da venda de drogas. Afirma estar arrependido de sua conduta. Por fim, informa não possuir filhos. Em Juízo, VICTOR HUGO confessou a prática delitiva. Relatou que passava por dificuldades, motivo pelo qual estava vendendo entorpecentes no local.

Pois bem; não há quaisquer dúvidas acerca da dinâmica dos fatos. Os policiais foram unânimes ao explicar que receberam a denúncia de que o acusado estaria realizando o tráfico pelo local, e conhecem aquele lugar como ponto de droga. Durante revista, encontraram 08 (oito) *ependorf's* de Cocaína ("crack") com peso líquido de 0,76 gramas (peso bruto 8,67gramas) e a quantia de R\$72,00 (setenta e dois reais), ao ser indagado sobre a droga e os valores, o réu espontaneamente disse aos policiais que em sua residência apenas teria um pouco mais de dinheiro, em diligências na residência do acusado, em seu quarto foi achado à quantia de R\$56,00 (cinquenta e seis reais), fruto das vendas de drogas.

Logo, nada há que desabone a versão dos gendarmes que estavam em contato direto com os fatos e relataram a ocorrência com coesão e harmonia. E, diante da quantidade de substância, resta indiscutível que a conduta da increpada amolda-se ao art.33 da Lei de Drogas.

Quanto à versão policial, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que "toda pessoa poderá ser testemunha". Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjetiva, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas.

Dessume-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente as fotografias do local dos fatos, autos de exibição e apreensão, laudos periciais, etc). Comungo do mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que "não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha" - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: "(...) Fundamentação da sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008. Em vetusta decisão da Suprema Corte, colige-se o posicionamento pacífico de que:

"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido" - HC 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 04/08/1998. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto "(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)" - HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018. Em idêntico sentir, "(...) não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado (...). É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ (...)" - HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017. Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexiste lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II) selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submete-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes - inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos - e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo. Aliás, consoante as ponderações do Excelentíssimo Desembargador Alcides Malossi Junior (excerto do voto da Apelação 1500527-90.2018.8.26.0471, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 24 de junho de 2020, sem grifos originais): "não há como se alegar que as palavras de funcionários públicos, diretamente envolvidos no evento, não mereçam credibilidade, porquanto foram sérias e harmônicas, não havendo nos autos qualquer elemento a demonstrar que estivesse ele a mentir, para imputar um delito a pessoa que soubessem ser inocente. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder deles, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito. Ademais, seria um contrassenso o Estado lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestar contas de suas atividades". Pontue-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem lastrear o édito penal condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a "condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...)" - HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009. De mais a mais, "é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido

de que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (...). Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do agente" - AP 618/RJ Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 13/12/2016.

Colige-se dos autos que não há qualquer indicio de que os policiais militares tenham confabulado, de forma vil e abjeta, para mentir na Delegacia e em Juízo, com o escopo de acusar uma pessoa inocente. Assim, não vislumbro margem para o acolhimento do pleito absolutório por fragilidade de provas.

- No mérito da imputação, cumpre destacar que este Magistrado compreende que o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, interpretado a contrario sensu, permite a análise casuística para se aferir se os entorpecentes são destinados a consumo próprio ou ao tráfico. Referido posicionamento também foi sufragado na Apelação 0045618-90.2015.8.26.0050, Rel. Des. Grassi Neto, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/06/2018. Ainda na seara exegética, também é aplicável o art. 51, inciso I, do mesmo diploma legal, para permitir o balizamento da situação fática perante a tipicidade em abstrato do delito de tráfico de drogas.

Segundo as diretrizes dos preceptivos em comento, analisando a natureza (cocaína) e a quantidade das substâncias apreendidas (08 (oito) eppendorf's de Cocaína ("crack"), com peso líquido de 0,76 gramas (peso bruto 8,67g), o local e às condições em que se desenvolveu a ação (enquanto promovia o tráfico no local), as circunstâncias sociais e pessoais, indiscutível que a droga era destinada a terceiros. Assim, não há que se cogitar em absolvição ou desclassificação, que são matérias de ordem pública e cognoscíveis ex officio.

O Egrégio Colegiado Bandeirante tem decidido, de forma assente e pacífica, que são as especificidades do caso concreto (quantidade e variedade das substâncias apreendidas, local dos fatos, desenvolvimento da conduta, antecedentes policiais/criminais do acusado, dentre outros dados empíricos) que permitem a análise e a conclusão da subsunção do fato ao art. 33 da Lei de Drogas, ou a eventual possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma. Em abono, vide precedentes: Apelação 0002856-33.2016.8.26.0597, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 10ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1500370-44.2019.8.26.0484, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1540082-77.2018.8.26.0451, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, 2ª Câmara de Direito Criminal, r. 11/05/2020.

Cumprido registrar que, para a caracterização do delito em tela, não se exige a finalidade lucrativa, tampouco que ao agente tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega de estupefaciente a usuários. Invoco ainda o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume Único, Editora Juspodium, 5ª edição, p. 1.007/1.012, sem destaques originais) que, em explanação quanto aos DEZOITO verbos e à tipicidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas, leciona o seguinte:

"Todas as condutas acima mencionadas têm o complemento ainda que gratuitamente, ou seja, sem cobrança de qualquer preço ou valor. Portanto, é de todo irrelevante haver ou não lucro, ou mesmo intuito de lucro. Os vários núcleos verbais constantes do art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade (...). Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que para a tipificação desse crime dispensa qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33. Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações

desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou o especial fim de agir)".

No mesmo sentir, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consoma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consoma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 3. A reavaliação dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado. 5. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 23/03/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INTENÇÃO DE TRAFICAR 329G (TREZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS) DE MACONHA APREENDIDOS COM O AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PRÁTICA DE UMA DAS DEZOITO CONDUTAS RELACIONADAS A DROGAS PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO PENAL. 1. "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido - AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 28/08/2019.

Considerando o posicionamento da doutrina e da jurisprudência, forçoso concluir que a tipicidade do crime de tráfico é extraída das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com todo o mosaico probatório. No caso em tela, a apreensão de considerável quantidade de cocaína e a quantia em dinheiro, permitem concluir, de forma indene de dúvidas, que a conduta amolda-se ao art. 33 da Lei de Drogas.

Com relação à CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA estampada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por se tratar de matéria de ordem pública, destaco a possibilidade de aplicação na situação em comento.

Verifico que a somatória das porções corresponde a 08 (oito) unidades. Não se trata de quantidade vultosa para os parâmetros locais, o que traz dúvida relevante quanto à dedicação ao tráfico e integração de organização criminosa.

Logo, os substratos probatórios colhidos são inócuos para demonstrar, de forma indene de dúvida, que o réu efetivamente dedicava-se ao comércio espúrio. Assim, pelo cenário de incerteza quanto à dedicação ao tráfico e participação em organização criminosa (notadamente pela reduzida quantidade de drogas e ausência de prova de reiteração delitativa), forçosa a aplicação do brocardo in dubio pro reo. Reputo que há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável. Destarte, plenamente convicto pela condenação de VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA por infração ao art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, passo à DOSIMETRIA DA PENA,

concorde ao critério trifásico do art. 68 do Estatuto Repressor.

Na primeira fase da dosagem, em respeito ao art. 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para alteração. Todavia, atento ao art. 42 da Lei Federal 11.343/2006, verifico que a natureza de uma das drogas pertencentes ao sentenciado (cocaína) é extremamente nociva à saúde pública, bem como detém alto poder destrutivo, causando assim um considerável grau de dependência. O Colendo Tribunal da Cidadania sedimentou o entendimento de que o crack e a cocaína justificam o incremento da sanção pela nocividade destas drogas. A respeito, vide os precedentes: AgRg no HC 476.995/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T. DJe 03/05/2019; HC 404.692/PB, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., DJe 08/05/2018; HC 306.565/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T. STJ, DJe 07/05/2015; HC 186.626/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 23/04/2012. Logo, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Já na segunda etapa da dosimetria, não incidem quaisquer circunstâncias genéricas agravantes (art. 61 do Código Penal). De outro vértice, reconheço a atenuante da menoridade relativa, pois VICTOR HUGO contava menos de vinte e um anos na data dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal), bem como da CONFISSÃO (Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Nos termos estabelecidos na Súmula 231 da Corte Cidadã, e na Repercussão Geral do Excelso Pretório (RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) não se mostra possível, nesta fase, reduzir a pena em parâmetro inferior ao estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Assim, reduzo a sanção intermediária ao piso de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase do procedimento dosimétrico, não noto a incidência de causas de aumento de pena previstas no Código Penal ou na Legislação Especial. Todavia, de outro vértice, vislumbro a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal 11.343/2006, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes do acusado. A despeito de se indicar o comércio, não há prova o bastante de que o réu se dedique efetivamente à atividade criminosa. Desta forma, considerando que foram apreendidas 20 porções de um único tipo de droga, reduzo a pena intermediária em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

- Da pós-dosimetria

Ausentes provas concretas acerca das condições financeiras e econômicas dos condenados, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal - ou seja, corresponderá a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 11.343/2006 c/c o art. 49, § 1º, Código Penal, pois inexistem elementos para estabelecer a reprimenda pecuniária acima do piso expresso na legislação especial e no diploma geral.

Em respeito ao estabelecido no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em se tratando de sentenciado primário e que ostenta circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do mesmo diploma), o quantum de pena aplicado e a natureza da sanção, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, de acordo com os verbetes sumulares 718 e 719 do Excelso Pretório.

Impende ainda salientar que se perfaz plenamente possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, tendo em vista o quantum de pena fixado (inferior a quatro anos), o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e ainda pela culpabilidade, antecedentes, a personalidade e conduta social do réu, os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que tal medida se afigura suficiente à reprovabilidade da conduta do réu e à prevenção criminal. No mais, a vedação do art. 44 da Lei de Drogas foi declarada inconstitucional pelo E. STF (vide o HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 01.09.10), razão pela qual cabe ao julgador analisar o caso concreto.

Logo, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MINIMO NACIONAL, de

sorte que todos os parâmetros serão definidos pelo Douto Juízo da Execução. O réu deverá ser expressamente ADVERTIDO de que, em caso de descumprimento, haverá a conversão da pena restritiva em sanção corporal, que será executada imediatamente. - Em arremate, atento ao disposto nos incisos do §2º do art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

De acordo com o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Manual de Processo Penal, 8ª edição, Editora JusPodivm, p. 1.094 e 1.611, sem destaques originais), "claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão, nos dias de hoje, é uma virtude, e em nada se revela incompatível com o disposto no art. 315, §2º, do CPP. Destarte, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação: aquela jamais dará ensejo à nulidade do art. 564, inciso V, do CPP, desde que enfrentadas, logicamente, todas as questões cuja resolução, em tese, tenham o condão de influenciar a causa".

No mais, prossegue o autor explicando que "quanto à necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto alibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria". Conforme já decidido pelo Excelso Pretório no tocante à fundamentação na seara do Direito Processual Penal, certo que "não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)" - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010.

Além disso, "(...) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017) (...)" - excerto da ementa do AgRg no HC 466.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça, DJe 10/05/2019.

Também é digno de nota que o mesmo Sodalício, em exame do art. 489 do Código de Processo Civil (cuja redação é idêntica ao do preceptivo introduzido no Código de Processo Penal pelo projeto chamado de "Pacote Anticrime"), firmou o posicionamento que "(...) conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) (...)" - excerto da ementa do REsp 1832993/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T. STJ, DJe 13/12/2019.

Dispositivo

1) Ante todo o exposto na fundamentação e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PAULO, e o faço para CONDENAR o acusado VICTOR HUGO DE SOUZA PEREIRA como incurso na descrição típica prevista no art. 33, §4º, da Lei Federal 11.343/2006 (Lei de Drogas), ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal.

2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, ressalvado o entendimento deste Magistrado, verifico que o réu respondeu solta ao processo. Assim, concedo o direito de recorrerem em liberdade.

3) Em face da condenação supra, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11.608/2003.

4) Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, determino que se proceda ao seguinte:

I) providencie-se o necessário à execução da pena imposta acima e cobre-se a taxa judiciária de acordo com as NSCGJ;

II) oficie-se ao TRE/SP, para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD;

V) comunique-se a Autoridade Policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do art. 72 da Lei de Drogas.

P.R.I.C."

Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Defensor(a):

Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Ré(u): Deseja recorrer desta

sentença: () Sim (X) Não. Ante a renúncia das partes do desejo de recurso, fica a r. Sentença prolatada transitada em julgado para as partes em 20/10/2022.

Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo, que lido vai devidamente assinado. Eu, , Bruno Luís Betti, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006